

学生Aと学生Bは、次の【事例】における甲の罪責について後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑧までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、乙に対し、殺意をもって、拳銃の引き金を引いて銃弾1発を発射し、乙の胸部に命中させて乙を殺害した。甲が拳銃で乙に狙いを付ける直前、乙は、甲に対し、殺意をもって、拳銃で狙いを付けて引き金を引こうとしていたものの、甲が発射した銃弾によって死亡したことから、引き金を引くには至らなかった。なお、甲は、乙が拳銃で自己に狙いを付けていることを知らなかった。

【会話】

学生A. 甲の行為は、殺人罪の構成要件に該当する。そして、正当防衛の成立要件として、防衛の意思が必要であると考えたと、甲には①(a. 殺人既遂罪が成立し・b. 正当防衛が認められ)、防衛の意思は不要であると考えたと、甲には②(c. 殺人既遂罪が成立する・d. 正当防衛が認められる)ことになる。

学生B. 最近では、防衛の意思必要説、不要説のいずれから、甲には殺人未遂罪が成立するという見解が有力に主張されている。防衛の意思必要説からの殺人未遂罪説は、違法性は行為無価値と結果無価値の総合から構成されるという違法二元論を根拠とし、③(e. 行為無価値の存在と結果無価値の欠如・f. 行為無価値の欠如と結果無価値の存在)を理由に、一方、防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説は、④(g. 適法・h. 違法)な結果が発生する具体的危険があることを理由に、それぞれ殺人未遂罪が成立し得ると説明している。

学生A. しかし、防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説に対しては、⑤(i. 「侵害はよいが侵害を試みることは許されない」・j. 「侵害を試みることはよいが侵害は許されない」)ことになるとの批判がある。

学生B. もともと、防衛の意思不要説からの殺人未遂罪説が問題にしている危険は、⑥(k. 別のあり得た違法結果・l. 当該結果)を発生させる危険ではなく、⑦(m. 別のあり得た違法結果・n. 当該結果)を発生させる危険と言われている。だから、その批判は当たらない。

学生A. いずれにせよ、殺人未遂罪説は、実際に乙が死亡しているのだから、罪刑法定主義上、問題があると思う。

学生B. 刑法第43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」と規定しており、これを、⑧(o. 構成要件の結果・p. 構成要件に該当する違法な結果)が発生しなかったという意味に理解すれば、文言解釈としての問題はないと思う。

1. ①a ②d ③e ④h ⑤i ⑥k ⑦n ⑧o
2. ①b ②c ③e ④g ⑤j ⑥k ⑦n ⑧p
3. ①b ②c ③f ④g ⑤j ⑥k ⑦n ⑧o
4. ①a ②d ③e ④h ⑤i ⑥l ⑦m ⑧p
5. ①a ②d ③f ④h ⑤j ⑥l ⑦m ⑧p

No84	防衛の意思	正答率
共通H27-7	正解 4	71%

() には順に、「① a ② d ③ e ④ h ⑤ i ⑥ l ⑦ m ⑧ p」と入り、したがって、正解は肢4となる。

①について

Aの第一発言から、甲の行為が殺人罪の構成要件に該当することは確定している。しかし、事案から明かなように、甲の行為は偶然にも防衛の効果が生じている。そこで、甲に正当防衛が成立するかが問題となる。正当防衛の成立要件として防衛の意思を必要と考えれば、防衛の意思がない甲には正当防衛は成立せず、殺人既遂罪が成立することになる。したがって、①には「a. 殺人既遂罪が成立し」が入る。

②について

正当防衛の成立要件として、防衛の意思を不要であると考えれば、甲の行為は、偶然とはいえ客観的な防衛の効果が生じているため、正当防衛が成立することになる。したがって、②には「d. 正当防衛が認められる」が入る。

③について

Bの第一発言からは、甲に殺人未遂罪が成立し得るという有力説を検討することが求められている。防衛の意思必要説を前提に、違法性は行為無価値と結果無価値の総合から構成されるという違法二元論を根拠とすれば、事案の甲には、行為自体の違法性があり、結果も発生しているものの、結果の違法性が欠けるため、殺人未遂罪が成立すると考えることができる。この考え方は、行為無価値の残存と結果無価値の欠如を理由とするものである。したがって、③には「e. 行為無価値の存在と結果無価値の欠如」が入る。

④について

防衛の意思不要説からの未遂説は、違法な結果が生じた可能性があったことを理由とする。したがって、④には「h. 違法」が入る。

⑤について

Aの第二発言では、防衛の意思不要説からの未遂説に対する批判を検討することが求められている。この見解に対しては、結果無価値を徹底すると結果だけでなく行為も正当化されるはずであるとの批判が向けられている。したがって、⑤には、結果は正当化されるが行為は正当化されない意味の文章が入ることになり、「i. 侵害はよいが侵害を試みることは許されない」が入る。

⑥⑦について

Bの第二発言では、Aの第二発言での批判を受けて、防衛の意思不要説からの未遂説の立場で再反論することが求められている。この立場が、問題にしている危険は、当該結果（正当化されている）を発生させる危険（これも正当化されている）ではなく、別のあり得た違法結果を発生させる危険であり、「侵害はよいが侵害を試みることは許されない」という場合の、前の「侵害」と後の「侵害」は別の侵害なのであるから、おかしい点はないと主張する。したがって、⑥には「l. 当該結果」が、⑦には「m. 別のあり得た違法結果」が入る。

⑧について

Bの第三発言では、直前のAの第三発言を受けて、未遂説でも罪刑法定主義上問題はないとする立場を検討することが求められている。現行法の未遂規定が構成要件の結果が不発生の場合だけを予定しているのだとすれば、未遂犯の成立を認めることは、罪刑法定主義上、問題がある。しかし、43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」とだけ規定しているため、これを、構成要件に該当する違法な結果を実現させなかった者を意味すると解することは、文言解釈として十分可能であると主張できる。したがって、⑧には「p. 構成要件に該当する違法な結果」が入る。